

1511596-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... da prisão, em local notório por ser ponto de tráfico de drogas, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 a Lei de Drogas.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

"PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511596-33.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511596-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE SANTOS VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

PAULO HENRIQUE SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo apurado, no 12 de maio de 2022, por volta das 13h15min, na Rua do Triunfo, 220, República, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, drogas, consistentes em 05 porções de cocaína pesando 3.8g (três gramas e oito decigramas), além de 21 porções de cocaína na forma de crack pesando 3.1g (três gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação. Após a manutenção do recebimento da denúncia, durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis metropolitanos e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou, em debates orais, pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou, a descon sideração dos memoriais que foram juntados erroneamente no termo audiência e pela apreciação das alegações constantes a fls. 158/162, nas quais requereu a absolvição do réu, notadamente pela ilegalidade da busca pessoal, que teria sido feita em dissonância com o previsto no CPP; ilegalidade da abordagem que fora feita pela Guarda Civil Metropolitana que não

teria atribuição legal para tal e consequente absolvição nos termos do art. 386, III do CPP. No mérito, propriamente dito, requereu ainda pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há provas suficientes para a condenação do acusado.

Por primeiro, não há que se falar busca pessoal ilícita, já que segundo os depoimentos dos autos, o réu foi abordado, por ter sido visto em meio a outras pessoas, em local conhecido como sendo ponto de trafico de entorpecentes e ainda porque, correu com a chegada da viatura e entrou em um bar.

Ora, diante desses fatos, não há como se falar que não havia fundada suspeita, que autorizasse a busca pessoal, nos moldes como previstas no art. no parágrafo único, do art. 240, do CPP.

Isso porque o que seria ainda mais necessário para configurar tal situação senão varias pessoas aglomeradas em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que um deles corre ao visualizar uma viatura da Guarda Civil Metropolitana?

Por outro lado, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, já que conforme descrito pelos guardas civis metropolitanos o réu "foi perseguido, logo após em situação que faça presumir ser autor da infração, ou seja, nos exatos termos do que dispõe o art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

Se não bastasse isso, muito embora não tenha a Guarda Municipal poder de polícia (art. 144, §8º da Constituição Federal), nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, qualquer agente público, incluindo os guardas civis metropolitanos estão aptos a efetuar a prisão em flagrante ao vislumbrar qualquer indivíduo cometendo crime, segundo a norma processual acima.

No caso em tela, a abordagem do réu se deu em local conhecido por ser ponto de trafico de entorpecentes, após ser visto em uma aglomeração de pessoas e correr.

A situação assim descrita não indica qualquer desvio de função dos agentes públicos. No contexto narrado, os guardas encontraram as drogas em poder do acusado, logo em seguida a perseguição, sendo que da detenção, seguiu-se rigorosamente à apresentação perante autoridade policial.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, § 8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'. (...) 4. Ordem denegada." (HC 109105 / SP - Quinta turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - Julgado em 23/02/2010)

Superadas as preliminares levantadas pela Defesa, verifica-se que a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação dos entorpecentes, pelo laudo pericial com resultado positivo para cocaína, bem como pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.

Com efeito, os dois guardas civis metropolitanos nas duas oportunidades em que prestaram suas declarações, foram enfáticos em afirmar que o réu foi visto juntamente com outras pessoas, em local típico de trafico de drogas e que ao visualizar a chegada da viatura todos correram sendo que o réu entrou em um bar onde foi detido e ao ser revistado com ele foram encontradas pedras de "crack" e papalotes de cocaína.

É fato que em juízo, disseram que o réu foi visto trocando alguma coisa com os outros indivíduos que estavam em sua companhia, tal fato, apesar de não constar das declarações iniciais, na fase policial, não são capazes de fulminar por completo a prisão do réu, como quis fazer crer a Defesa, já que o réu estava aglomerado com outras pessoas, em situação típica de compra e venda de drogas e correu no momento em que viu a guarda civil, não sabendo esclarecer o motivo pelo qual estava com drogas de formas variadas no momento em que foi preso.

Isso porque, ao ser interrogado, Paulo Henrique, não negou que estivesse na posse das drogas apreendidas, mas disse que elas eram apenas para seu uso próprio. Em juízo, disse que já estava dentro do bar jogando nas maquininhas "caça níquel" e saiu para comprar drogas e ao voltar foi preso. Não soube contudo, esclarecer, o motivo pelo qual trazia consigo pedras de crack e cocaína, nem tão pouco relatar o motivo pelo qual gastou mais dinheiro com aquisição de cocaína na forma de pó, (droga sabidamente de valor mais elevado), já que é viciado em "crack". Além disso, sua versão contudo, não veio corroborada por outras provas, e neste sentido, bastaria que ele ao menos esclarecesse a variedade das drogas com ele encontradas e ainda, porque, não comprou as drogas antes do início do jogo e sim saiu e voltou bem no momento em que as pessoas ali estavam e a viatura da guarda civil metropolitana passou.

Tais fatos, não foram comprovados e assim são considerados incríveis por essa magistrada ainda mais se tomarmos por base o depoimento dos guardas civis metropolitanos, que embora com algumas divergências pontuais nas duas oportunidades em que foram ouvidos, disseram que o réu estava com outras pessoas em situação típica de tráfico de entorpecentes e correu no momento em que viu a viatura, sendo detido ainda na posse de drogas.

Portanto, essas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não há que se falar em absolvição do acusado. Cabe ainda, aqui destacar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem guardas municipais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais e agentes públicos aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial ou guarda municipal somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos, indício que qualquer tipo de perseguição pelos guardas civis contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por fim, a variedade droga apreendida em poder do acusado, e as circunstâncias da prisão, em local notório por ser ponto de tráfico de drogas, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 a Lei de Drogas.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

"PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São

Paulo - 05.05.94).

Neste ponto afasta-se por completo o requerimento de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art.28 do diploma legal citado. Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, tendo sido condenado definitivamente por crime de roubo, autos 0042611-37.2008.8.26.0050, consoante certificado a fls. 34, já que a pena referente ao crime julgado pela 28ª Vara Criminal, somente foi extinto em 27/08/2019, o que será levando em consideração na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso já foi condenado definitivamente por outro crime perante a 7ª Vara Criminal local, autos nº 7000025-62.2006.8.26.0266, que se encontra extinto, fato este que será tido como maus antecedentes, devendo sua pena ser aumentada em 1/6, notadamente por sua personalidade voltada para o crime, perfazendo 05 anos 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Não há que se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminoso do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Veja-se que a expressão "muito antigas", utilizada por vezes, para requerer o afastamento das condenações por parte da combativa Defesa é imprecisa e pode por vezes levar a situações de injustiça e até de quebra do princípio da individualização da pena, devendo o critério do julgador ser objetivo e fundado em fatos concretos, como os aqui apontados.

Também não há que se falar em desconsideração do fato, posto que extinto pela prescrição, já que se trata prescrição da pretensão executória (fls. 34), que permite o reconhecimento do crime praticado pelo réu, sendo que somente sua punição não pode mais ser executada.

Na segunda fase, em face da reincidência a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de tráfico, diante de reincidência e de prova que se dedica a atividades criminosas, já que ao ser solto, novamente voltou a delinquir e foi preso desta vez, por tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir agora como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, como vem decidindo nossas cortes superiores.

Isto porque, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de

tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado". Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro). Fixo o dia-multa no mínimo legal estabelecido já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para CONDENÁ-LO à pena de 06 anos, 09 meses, 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como sua reincidência, o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

No mais, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a decisão que determinou sua prisão preventiva.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Se o caso, autorizo toda destruição das drogas apreendidas, oficiando-se neste sentido.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA